

第41問

Xは、知人Aから3カ月間の約束でノートパソコンと50万円を貸して欲しいと頼まれた。そこで、Xは、自己名義の預金口座から50万円を引き出してAに渡すと共に、父親Bが友人Cから借りていたノートパソコンをBの所有物であると思い、Bの書斎から無断で持ち出してAに貸した。Aは、パソコンは返したものの、50万円は返済期限を2カ月過ぎても返そうとしないので、Xは、連日電話で催促したが、Aには全く返す気配がなかった。いつまでも返してくれないことに腹を立てたXは、ある日、たまたま路上でAに出会ったので、「返さないとただではおかないぞ。痛い目にあいたいのか。明日までに返せ。」などと申し向け、これに畏怖したAは翌日50万円をXに返済した。

Xの罪責を論ぜよ。

(神戸大学法科大学院 平成16年度)

第1 Bの書斎からノートパソコンを無断で持ち出した行為について

- 1 窃盗罪（235）の成否において、不法領得の意思の有無が問われる（**論点** 不法領得の意思  司H27,H29,旧H1-2,H19-2）。

 総合 198 頁  論証 85 頁

不法領得の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいう」（最判昭26.7.13）とされている。この前半部分を権利者排除意思、後半部分を利用処分意思という。このうち、本問では、権利者排除意思の有無が問題となるが、Xは3か月間にわたって持ち出す意思を有していたのだから、当然肯定できる。

- 2 ただし、占有者BとXには親族関係が認められるから、244条の適用の有無が問題となる（**論点** 親族間の特例（244）の法的性質  旧H20-2、**論点** 244条における親族関係は誰と誰との間に必要か）。

 総合 202 頁

 総合 202 頁  論証 86 頁

- (1) 判例（最決平6.7.19）は、「窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法244条1項が適用されるためには、同条1項所定の親族関係は、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要するものと解するのが相当である」として、同条の親族関係は、所有者・占有者・本犯者全員に必要であると解している。

本問では、ノートパソコンの所有者は父親Bの友人であるCであるから、244条の適用はない。

- (2) 次に、親族関係に錯誤があった場合の処理が問題となるが、故意を阻却しないと考えるのが通説である（**論点** 親族関係の錯誤（244） 旧H20-2）。

 総合 202 頁  論証 86 頁

第2 「痛い目にあいたいのか」などと申し向け、Aに借金を返済させた行為について

恐喝罪（249 I）の成否を検討することになるが、いわゆる権利行使と恐喝の論点が生じる（**論点** 権利行使と恐喝  司H19,R2）。

 総合 237 頁  論証 110 頁

判例は、3万円の債権を有している者が6万円を喝取した事案について、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする」と判示した（最判昭30.10.14【百選Ⅱ61】）。この判例は、金銭債権の行使であっても被害者を畏怖させて財物を交付させている限り、恐喝罪の構成要件該当性が肯定されるが、権利の範囲内で、しかも、その方法が社会通念上忍容すべきものであれば、違法性が阻却されるという判断枠組みを採るものと理解されており、恐喝罪成立肯定説をとる。

そこで、「その方法が社会通念上一般に忍容すべきもの」として違法性阻却が認められるかが問題となるが、「返さないとただではおかないぞ。痛い目にあいたいのか。」として身体に危害を加える旨を申し向けていることから、基本的には、「その方法が社会通念上一般に忍容すべ

きもの」とは言い難いだろう。裁判例の中には、債務者が書類を偽造したり、虚言を弄したりして不誠実・悪質な交渉態度をとったことを考慮して受忍限度の範囲内にあるとしたものもある（京都地判平10.2.25など）が、本問ではそこまでの事情は認められない。

もっとも、Aが返済期限を2か月過ぎても返そうとしないこと、Xは、連日電話で催促したが、Aには全く返す気配がなかったこと、債権額以上のものを要求しているわけではないこと（裁判例において、恐喝罪の成立が肯定されている事案は、債権額以上のものを要求している事案が多く、損害の実質が考慮されているとみられる。）を重視すれば、「その方法が社会通念上一般に忍容すべきもの」に当たるといふ余地もある。

答案構成

第1 Bの書斎からノートパソコンを無断で持ち出した行為について

1 窃盗罪(235)



客観的構成要件該当性、故意(38 I)は問題なし



2 不法領得の意思に欠けるところはないか



必要説



権利者排除意思、利用処分意思で判断する



3 あてはめ



4 窃盗罪成立



5 244条1項の適否



誰と誰との間に親族関係が必要か



窃盗犯人と所有者及び占有者双方との間に必要



あてはめ



244条1項の適用なし



親族関係に錯誤がある場合の処理



故意を阻却しない

第2 「痛い目にあいたいのか」などと申し向け、Aに借金を返済させた行為について

1 恐喝罪(249 I)の成否



2 権利行使と恐喝



恐喝罪説



権利の範囲内であり、その方法が権利行使の方法として社会通念上
認容すべき態様のものであれば、例外的に違法性が阻却される



3 あてはめ



4 恐喝罪成立

第3 罪数

Xには窃盗罪と恐喝罪が成立し、両者は併合罪（45前段）の關係に立つ

第1 Bの書斎からノートパソコンを無断で持ち出した行為について

1 XはBの書斎から無断でノートパソコンを持ち出しており、Bの意思に反して財物の占有を移転させているから、「財物を窃取した」といえる。そのため、Xの行為は窃盗罪（235条）の客観的構成要件に該当する。また、Xにはその点の認識もあるから、故意（38条1項）に欠けるところもない。

2 しかし、Xはノートパソコンを3か月間Aに貸した後にこれを返還する意図（一時使用目的）であったと考えられることから、不法領得の意思がなく、窃盗罪が成立しないものとも思われる。

ここで、領得罪の成立には、不法領得の意思が必要であると解すべきである。かかる主観的超過傾向を不要とすれば、不可罰な使用窃盗と窃盗罪との区別、さらに、窃盗罪と毀棄罪との区別が困難になるからである。

そして、その内容としては、両者の観点を考慮すべく、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思であると解する。

3 本問では、Xはノートパソコンを返却する意思を有してはいたが、3か月間にわたって持ち出す意思を有していた。このように一般に権利者が許容しないであろう程度・態様の利用をする意思がある場合は①の意思が認められる。また、Xは、Aに貸すという形でノートパソコンを経済的に利用する意思があるので、②の意思も認められる。

よって、Xには不法領得の意思が認められる。

1

4 以上から、Xには窃盗罪が成立する。

5(1) そうだとしても、当該ノートパソコンはXの父Bが占有していたことから、244条1項によって刑が免除される可能性がある。

もっとも、所有者はXの父Bの友人Cであり、Xとの間に親族関係がない。そこで、同条の親族関係は誰と誰との間で必要か問題となる。

同条は、「法は家庭に入らず」という趣旨に基づき政策的に刑を免除する規定と解すべきところ、所有者と占有者が異なる場合、その双方と犯人との間に親族関係がなければ、そのような趣旨は妥当しない。

そこで、親族関係は窃盗犯人と所有者及び占有者双方との間に必要であると解する。

本問では、犯人Xと所有者Cとは親族関係がないことから、244条1項の適用は否定される。

(2) もっとも、Xは所有者を父Bと誤信しており、親族関係に錯誤が生じている。そこで、かかる錯誤が犯罪の成否ないし244条1項の適用に影響しないかが問題となる。

244条の法的性質は、上記のように政策的な一身の処罰阻却事由であるから、故意の対象ではない。

よって、客観的に親族関係が存在しない場合には刑の免除は認められず、親族関係に錯誤が生じている点は量刑事情として考慮されるにすぎないものと解する。

2

(3) 以上より、Xには窃盗罪が成立し、その刑は免除されない。

第2 「痛い目にあいたいのか」などと申し向け、Aに借金を返済させた行為について

1 次に、Xは、「痛い目にあいたいのか」などと脅迫的言辞を用いて、
Aに借金を返済させている。そのため、「人を恐喝して財物を交付させ
た」といえ、恐喝罪(249条1項)が成立する可能性がある。

しかし、Aは債務の弁済をしたにすぎず、財産上の損害がないとも思
われる。恐喝罪は財産罪であるから、財産上の損害が認められなけれ
ば、同罪は成立しないことになる。恐喝罪における損害の発生について
いかに解すべきか。

2(1) 249条1項が畏怖させて財物を交付させる行為自体を処罰してい
ることに鑑みれば、恐喝罪は個別財産に対する罪であり、財物の交付
自体が損害といえる。

したがって、畏怖しなければ交付しなかったであろうと認められる
場合には、たとえ債権額の範囲内であっても、恐喝罪が成立し得ると
解する。

(2) ただし、権利の範囲内であり、その方法が権利行使の方法として社
会通念上認容すべき態様のものであれば、例外的に違法性が阻却され
ると解するのが相当である。

3 これを本問についてみると、Aは、返済期限を2か月過ぎても返そう
とせず、Xが、連日電話で催促したにもかかわらず、Aには全く返す気
配がなかったのだから、Aは畏怖しなければXに即座に返済しなかった

3

であろうと認められる。

しかし、Xの「痛い目にあいたいのか」と脅す行為は、Aの身体に危
害を加えることを申し向けるものであり、上記のようなAの態度を考慮
したとしても、社会通念上認容すべき態様とはいえ、違法性は阻却さ
れない。

4 よって、Xに恐喝罪が成立する。

第3 罪数

以上より、Xには窃盗罪と恐喝罪が成立し、両者は併合罪(45条前
段)の関係に立つ。

以 上

4